

刑法
No.321

予備独自問題 R 4-4

(配点: 2)

月 日

月 日

背任罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、信用保証協会の支所長であり、金融機関が中小企業者等に対して行う融資に関して、信用保証をなす業務を行っていたところ、乙の利益を図る目的で、乙に返済能力がないことを知りながら、乙が金融機関から融資を受けるに際し、確実かつ十分な担保の徴求をしないまま、同協会にその保証債務を負担させた。この場合、乙の金融機関に対する債務がいまだ不履行の状態に至らず、上記協会に、代位弁済による現実の損失がいまだ生じていなくても、甲に背任罪が成立する。
- イ. 甲は、乙から頼まれ、乙が丙に対する貸金債権の質物として提供を受けていた丙所有の絵画を甲の自宅倉庫で保管していたが、乙に嫌がらせをする目的で、同絵画を乙に無断で丙に返還した。この場合、甲に背任罪が成立する。
- ウ. 甲は、乙が自身の有していた丙に対する債権を丁に譲渡した後、丁が対抗要件を具備する前に、同債権が丁に譲渡済みであることを確実に知りながら、同債権を転売して利益を得る目的で、乙に強く働き掛けて、乙から同債権を譲り受け、その対抗要件も具備した。この場合、甲と乙はいわゆる必要的共犯の關係に立つため、甲に背任罪の共同正犯が成立することはない。
- エ. 甲は、返済期日までに返済できないときは同期日に改めて甲の所有する土地に抵当権を設定する旨を述べて、乙を安心させて乙から金を借りたが、同期日が到来する前に、丙に対する借金を返済する目的で、乙に無断で同土地を丙に売却した。この場合、甲に背任罪が成立する。
- オ. 甲は、債権者乙との間で甲所有家屋を目的とする根抵当権設定契約を締結し、乙にその登記に必要な登記済証、白紙委任状及び印鑑証明を交付していたが、乙がその登記をしない間に、自らの利益を図る目的で、丙から金を借りて同家屋に根抵当権を設定し、丙が第1順位の根抵当権設定登記を了し、乙はそのために債権の回収が困難になった。この場合、甲に背任罪が成立する。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 正しい

最決昭 58.5.24 (百選Ⅱ72 事件) により、本記述は正しい。

判例は、本記述と同様の事案において、背任罪 (247 条) の成立を認めている。その理由として、判例は、同条の「本人に財産上の損害を加えたとき」とは、「経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかつたときをいうと解すべきであるところ、被告人が本件事実関係のもとで同協会をして乙の債務を保証させたときは、同人の債務がいまだ不履行の段階に至らず、したがって同協会の財産に、代位弁済による現実の損失がいまだ生じていないとしても、経済的見地においては、同協会の財産的価値は減少したものと評価される」から、「本人に財産上の損害を加えたとき」に当たるとしている。したがって、甲には、背任罪が成立する。

イ 正しい

大判明 44.10.13 により、本記述は正しい。

判例は、本記述と類似の事案において、委託物横領罪 (252 条) の成立を否定し、背任罪 (247 条) の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、委託物横領罪の保護法益は第 1 次的には所有権、第 2 次的には委託信任関係であるから、質権を侵害しても所有権の侵害はなく、委託物横領罪は成立しないということを挙げている。したがって、甲には、背任罪が成立する。

ウ 誤っている

本記述は、甲に背任罪の共同正犯が成立することはないとしている点で、誤っている。

まず、債権を二重譲渡した乙には、丁との関係で背任罪 (247 条) が成立するが、関与した甲につき、同罪の共同正犯は成立するか。必要的共犯は多衆犯と対向犯に分かれ、さらに対向犯は、対向者双方に同一の法定刑が規定されている場合、異なった法定刑が規定されている場合、対向者の一方のみが処罰される場合 (片面的対向犯) とに分かれるところ、背任罪において、取引の相手方は、背任罪に当然に伴う一種の必要的共犯 (片面的対向犯) ともいえるが、単なる関与にとどまらず、背任行為の実現に積極的に加担し、犯罪遂行への重要な事実的寄与をしたような場合には、背任罪の共同正犯が認められている (最決平 20.5.19 など)。本記述の甲は、債権が丁に譲渡済みであることを確実に知りながら、同債権を転売して利益を得る目的で、乙に強く働き掛けており、背任行為の実現に積極的に加担している。したがって、甲には、背任罪の共同正犯が成立し得る。

エ 誤っている

本記述は、甲に背任罪が成立するとしている点で、誤っている。

背任罪 (247 条) の主体は、「他人のためにその事務を処理する者」、すなわち、他人に対する内部関係において一定の任務に従って他人の事務を処理すべき信任委託関係を有する者である (真正身分犯)。この信任委託関係は、法令、契約のほか、判例によれば、慣習や事務管理によっても発生するが、他人に対する信任委託関係に基づいて他人の事務を処理する者でなければならない (例えば、売買や金銭消費貸借などの双務契約における各当事者は、相手方に債務を負っているが、この債務履行は他人に対する自己の事務にすぎないから、他人の事務処理者に当たらない)。本記述の甲は、返済期日までに返済できないときは同期日に改めて甲の所有する土地に抵当権を設定する旨を述べて、乙を安心させているにとどまり、乙との間で抵当権設定契約を締結したとはいえない。よって、甲は、「他人のためにその事務を処理する者」に当たらない。したがって、甲に背任罪は成立しない。

オ 正しい

最判昭31.12.7（百選Ⅱ70事件）により、本記述は正しい。

判例は、本記述のような二重抵当の事案において、背任罪の成立を認めている。その理由として、判例は、「抵当権設定者はその登記に関し、これを完了するまでは、抵当権者に協力する任務を有することはいうまでもないところであり、右任務は主として他人である抵当権者のために負う」こと、また、「抵当権の順位は当該抵当物件の価額から、どの抵当権が優先して弁済を受けるかの財産上の利害に関する問題であるから、……1番抵当権を、後順位の2番抵当権たらしめたことは、……刑法247条の損害に該当する」ということを挙げている。したがって、甲には、背任罪が成立する。

以上により、誤っている記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。